

1501991-49.2021.8.26.0535

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

Comarca: Arujá

Foro: Foro de Arujá

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/04/2022

... para uso pessoal e não admitiu o tráfico.

Incide a causa especial de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V), lembrando-se que para sua caracterização "é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual" (Súmula 587, STJ).

Esse elemento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Arujá

Foro de Arujá

2ª Vara

Avenida Albino Rodrigues Neves, 394, Aruja-SP - cep 07401-125

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1501991-49.2021.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501991-49.2021.8.26.0535

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2208800/2021 - DEL.POL.ARUJA, 19394842 - DEL.POL.ARUJA, 1372/21/201 - DEL.POL.ARUJA, 2208800 - DEL.POL.ARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSÉ HENRIQUE OLIVEIRA GOMES

A) RELATÓRIO

DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", c/c 40, incisos III e V, ambos da Lei 11.343/06.

Segundo a denúncia, "Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no 03 de agosto de 2021, por volta das 16h45min, na altura do Km 204 da Rodovia BR 116 (Rodovia Presidente Dutra), sentido Rio de Janeiro, Bairro Jardim Joia, nesta cidade e comarca de Arujá/SP, o indiciado DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES, transportava e trazia consigo, em transporte público, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 04 (quatro) porções de Cannabis sativa L., droga popularmente conhecida como maconha, com peso total, líquido, 490,96 (quatrocentos e noventa gramas), substância capaz de causar dependência física e psíquica, conforme auto de apreensão de fls. 8, laudo de Constatação de fls. 11/13

e laudo de exame químico-toxicológico a ser juntado" (fls. 68/70).

O flagrante foi convertido em prisão preventiva (fls. 38/39).

Foi notificado (fls. 124) e apresentou defesa prévia (fls. 134/139). Recebida a denúncia (fls. 154), realizou-se audiência de instrução, debates e julgamento, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas arroladas e o réu interrogado.

Encerrada a instrução, o Ministério Público requereu o acolhimento dos pedidos, nos termos da denúncia, com exceção da causa especial de aumento relativa ao transporte público. Em síntese, a defesa requereu a descCLASSIFICAÇÃO para o crime de porte de drogas para o uso pessoal; a aplicação da figura do tráfico privilegiado; a fixação da pena no mínimo legal, com regime inicial mais favorável; substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

B) ANÁLISE DO CASO CONCRETO

Imputa-se a prática do seguinte crime da Lei 11.343/06:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

"Art. 40. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei são aumentadas de um sexto a dois terços, se:

III - a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos; V - caracterizado o tráfico entre Estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal."

A pretensão punitiva é procedente.

O fato existiu. A materialidade está comprovada pela prova oral produzida; boletim de ocorrência (fls. 5/7); auto de exibição e apreensão (fls. 8); laudo de constatação provisório (fls. 11/13) e laudo pericial definitivo (fls. 198/199), que atestam que a substância encontrada era de uso proibido pela Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998 (4 porções com 490,96 gramas líquidas de maconha). Também não há dúvida da autoria.

A testemunha Weber Luiz Pinto Martins disse em sede policial que "É Policial Rodoviário Federal e nesta data encontra-se em serviço juntamente com o também policial rodoviário federal Arjona, e que ambos estavam em Operação Comando junto a Praça do Pedágio do Km:204, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, lograram êxito em abordar o ônibus da viação Águia Branca que fazia a linha São Paulo/Vitória; Que adentraram ao interior do veículo e começaram a indagar os passageiros sobre o que havia no interior das bagagens, sendo que o passageiro da poltrona 51, identificado como Daniel de Oliveira Rodrigues, afirmou que no interior de sua bagagem que haviam drogas no interior de sua bagagem, indagado que tipo de drogas, o mesmo afirmou que era maconha, e que havia comprado tal droga no bairro de Santana em São Paulo, pagando a quantia de R\$1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais) e que levaria a droga para sua região no município de Guarapari para consumo próprio, bem como fora apreendido um aparelho de telefone celular o qual estava em poder de Daniel de Oliveira Rodrigues; Diante disto o depoente exarou voz de prisão em flagrante delito para Daniel de Oliveira Rodrigues, sendo o mesmo conduzido até esta Delegacia de Polícia, onde a Autoridade deliberou pela

apreensão de seu aparelho de telefone celular e das drogas encontradas em seu poder, sendo tais drogas encaminhadas ao Instituto de Criminalística de Guarulhos; Em tempo, em obediência ao art. 304 do CPP, emprestou a Autoridade, neste ato, RECIBO pela entrega do(s) capturado(s), determinando, com os recursos disponíveis (ressalvada a hipótese de colaboração espontânea de outras instituições) a custódia do(s) agente(s) em dependência designada, dotada de suficiente vigilância acauteladora para ulterior encaminhamento ao sistema prisional" (fls. 2). Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que sua equipe estava fazendo fiscalização no pedágio de Arujá, avisou o ônibus Itapemirim de São Paulo com destino a Vitória. O réu se mostrou um pouco confuso desde o início. Ele tinha uma bagagem em suas pernas, ao abrir a bagagem ele já admitiu que tinha droga, informou que se tratava de maconha. Ele informou que teria comprado em Santana, pagou R\$1.600,00, alegou que seria para consumo pessoal.

A testemunha Eduardo Arjona Barreto Silva disse em sede policial que "É Policial Rodoviário Federal e nesta data encontra-se em serviço juntamente com o também policial rodoviário federal Weber, e que ambos estavam em Operação Comando junto a Praça do Pedágio do Km:204, da Rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, lograram êxito em abordar o ônibus da viação Águia Branca que fazia a linha São Paulo/Vitória; Que adentraram ao interior do veículo e começaram a indagar os passageiros sobre o que havia no interior das bagagens, sendo que o passageiro da poltrona 51, identificado como Daniel de Oliveira Rodrigues, afirmou que no interior de sua bagagem que haviam drogas no interior de sua bagagem, indagado que tipo de drogas, o mesmo afirmou que era maconha, e que havia comprado tal droga no bairro de Santana em São Paulo, pagando a quantia de R\$1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais) e que levaria a droga para sua região no município de Guarapari para consumo próprio, bem como fora apreendido um aparelho de telefone celular o qual estava em poder de Daniel de Oliveira Rodrigues; Diante disto o policial rodoviário federal Weber exarou voz de prisão em flagrante delito para Daniel de Oliveira Rodrigues, sendo o mesmo conduzido até esta Delegacia de Polícia, onde a Autoridade deliberou pela apreensão de seu aparelho de telefone celular e das drogas encontradas em seu poder, sendo tais drogas encaminhadas ao Instituto de Criminalística de Guarulhos" (fls. 3)

Em Juízo, reiterou sua versão dos fatos. Disse que estava em fiscalização de rotina no pedágio e deu ordem de parada no ônibus com destino a vitória. Ao chegar na poltrona 51 o réu tinha uma bagagem de cor rosa embaixo da poltrona. Quando abriu a mochila encontrou sacolas com maconha. O réu disse que iria comprar a droga para consumo pessoal. Disse que comprou a droga no bairro de Santana e pagou por isso R\$1.600,00. Disse que foi para São Paulo a turismo e aproveitou a viagem para fazer a compra em Santana. Ele estava sentado como todos os outros passageiros.

O réu Daniel de Oliveira Rodrigues disse em interrogatório na fase policial que "é Empresário sendo proprietário de um restaurante de médio porte localizado em uma das praias do município de Guarapari no Estado do Espírito Santo, que é viciado em maconha desde os treze anos de idade, e até a presente data mantém o vício, que um amigo seu lhe indicou um local no bairro de Santana no município de São Paulo, onde tinha maconha de qualidade boa, uma vez que no município de Guarapari, não tem maconha de qualidade boa, diante disto o interrogado veio até este município, onde ficou hospedado por cerca de um dia em um hotel, e que pagou a quantia de R\$1.600,00 (Hum Mil e Seiscentos Reais) para levar a droga até sua cidade de Guarapari, para consumo próprio, porém quando estava voltando para a cidade de Vitória no ônibus da viação Águia Branca, no km:204, da praça do pedágio deste município, o ônibus fora abordado por policiais rodoviários federais, os quais adentraram ao interior do veículo e começaram a indagar os passageiros sobre o que havia no interior de suas bagagens, que o interrogando demonstrando muito nervosismo acabou confessando que havia drogas mais precisamente maconha no interior de sua mochila, diante disto acabou sendo preso em flagrante delito, pela prática do crime de tráfico de drogas, que não registra antecedentes criminais". (fls. 4)

Em Juízo, disse que não estava traficando. Veio para São Paulo para passear, ficou esperando em um hotel, um amigo pegou essa quantidade de droga, que seria para

consumo pessoal. Consome maconha todos os dias praticamente, fumava desde os 13 anos. Não comprou essa quantidade em sua cidade pois não gostava de ir na biqueira. Ficaram dois dias em São Paulo. Seu amigo estava no mesmo ônibus, mas na fileira de trás.

Embora a inocência deva ser presumida, ao final da instrução a acusação cumpriu seu ônus de demonstrar os fatos alegados na denúncia.

Com efeito, os policiais rodoviários federais confirmaram em Juízo que abordaram o réu durante fiscalização de rotina no pedágio de Arujá, na rodovia Presidente Dutra, no interior de ônibus com origem de São Paulo e destino a Vitória - ES. O réu demonstrou nervosismo. Os policiais encontraram em uma bolsa que estava com o réu uma sacola com quatro porções com total de quase meio quilo de maconha. Não há nada nos autos que evidencie que o agente de segurança tenha motivo para incriminar o réu de forma proposital. Por isso, deve prevalecer a versão do agente público, que age presumidamente na forma a lei, e cujo relato é coerente com a dinâmica dos fatos e demais provas existentes no processo. A jurisprudência é farta nesse sentido.

Por outro lado, o réu não trouxe qualquer elemento que contrariasse tais premissas, sendo certo que o ônus da "prova da alegação incumbirá a quem a fizer" (art. 156, CPP). Ao contrário, admitiu que a droga era sua, embora tenha afirmado que se destinava ao consumo pessoal.

O tráfico de drogas não se consuma apenas com o ato típico de "venda". Se o acusado pratica qualquer uma das 18 condutas descritas no art. 33 da Lei 11.343/06 terá incorrido no crime, inclusive na hipótese de apenas "ter em depósito", "guardar" ou "trazer consigo" a droga.

Mesmo a conduta de "oferecer" não exige a finalidade lucrativa, pois a lei tipifica as condutas praticadas "ainda que gratuitamente". Na realidade, o intuito de lucro é apenas uma circunstância negativa que justifica aumento da pena. Por isso, não se exige um elemento subjetivo especial, ou seja, a demonstração da intenção específica de praticar atos de mercancia. Basta o dolo genérico, a consciência e vontade de realizar alguma das ações que configuram o crime e dispensam intenção de venda.

O elemento subjetivo é determinante apenas para se descartar a hipótese de porte ou guarda da droga para uso pessoal, o que ensejaria a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Segundo o §2º deste dispositivo, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Sobre o tema, é relevante observar que o tráfico muitas vezes é praticado por indivíduos com pequenas porções, justamente para tentar ludibriar a repressão estatal. Por isso, a análise da quantidade é sempre relativa, a partir da realidade local e demais circunstâncias, sob pena de se admitir a livre circulação de entorpecentes sem que exista tráfico, o que é logicamente impossível.

Feita essa ressalva, no caso concreto a quantidade não era compatível com a figura de mero usuário, quase meio quilo de maconha. A alegação do réu de que a droga seria para consumo pessoal é inverossímil, não sendo razoável supor que o réu iria viajar longa distância apenas para comprar o entorpecente que, segundo o réu, consumiria todos os dias. Como bem indicou o Ministério Público em alegações finais, o réu não soube explicar a finalidade da viagem, que teria durado apenas dois dias, os locais onde visitou, etc. Sua versão é fantasiosa.

Por fim, o simples fato de eventualmente ser usuário não afasta a configuração do tráfico, já que esses elementos não são excludentes.

Logo, está bem caracterizado o tráfico de drogas.

A prova é coesa e harmônica no sentido de que o réu conscientemente praticou o delito, realizando todos os elementos da norma incriminadora. Há tipicidade formal e material. Sua conduta foi contrária ao direito, era imputável, tinha potencial consciência da ilicitude de seus atos e lhe era exigível comportamento diverso. A condenação é medida que se impõe.

C) DOSIMETRIA

O Juiz deve concretizar a individualização da pena (art. 5º, XLVI, CF) analisando as particularidades da infração e condições pessoais do réu, buscando uma pena "suficiente para reprovação e prevenção" (art. 59, CP).

O objetivo é fixar uma pena justa para a situação concreta, diferenciando-a das inúmeras outras em que o mesmo crime poderia ser cometido, por diversas pessoas e seus motivos, diferentes formas de execução, consequências individuais e coletivas. Na primeira etapa, as frações de aumento devem incidir preferencialmente sobre o intervalo abstrato entre a pena mínima e a máxima. Esse critério é mais adequado especialmente em crimes nos quais a distância entre as penas mínimas e máximas é expressiva, tal como no tráfico de drogas, cuja pena varia de 5 a 15 anos de reclusão. Se aplicada a fração de aumento sobre a pena mínima, a reprimenda nunca iria superar 10 anos de reclusão na primeira fase, mesmo em casos graves (aumento de 8/8). Isso deixaria de considerar toda a margem de variação prevista pelo legislador e tornaria a pena injusta.

Assim, "embora não haja vinculação a critérios puramente matemáticos, os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais, da prestação de contas (accountability) e da isonomia exigem que o julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos" (grifei).

Nos crimes da Lei 11.343/06 merecem destaque ainda "a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente" (art. 42). O réu é tecnicamente primário.

A natureza e a quantidade de drogas autorizam o aumento da pena base, dado seu maior potencial destrutivo e viciante, acarretando igualmente maiores transtornos sociais e esforços do Poder Público em combatê-los. Contudo, tais elementos serão levados em consideração apenas na modulação do grau de redução na terceira fase, sem prejuízo da repercussão dessas circunstâncias negativas no regime inicial e demais benefícios.

Fixo a pena base no mínimo legal.

Não incidem agravantes ou atenuantes, lembrando-se que o réu alegou que a droga seria para uso pessoal e não admitiu o tráfico.

Incide a causa especial de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V), lembrando-se que para sua caracterização "é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual" (Súmula 587, STJ).

Esse elemento por si só justifica aumento da pena em 1/5, acima da fração mínima (1/6), por envolver não apenas o abastecimento de outro ponto de venda de drogas, mas também a articulação entre dois grupos criminosos e a consolidação de rotas de tráfico. Isso é especialmente sensível na Comarca, que fica nas margens da Rodovia Presidente Dutra, com todas as graves implicações sociais inerentes, exigindo-se maior repreensão pelo Estado.

Afasto a causa especial de aumento tráfico em transporte público (art. 40, III), considerando que não há prova de que o réu forneceu ou iria fornecer a droga aos demais passageiros, ou que a transportava de maneira ostensiva. Atualmente esse requisito é exigido jurisprudência.

A pena atinge 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Sendo o réu primário e inexistente outra ação penal em curso, viável a aplicação da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, Lei 11.343/06). Contudo, a redução é feita no patamar mínimo (1/6), considerando que a quantidade de droga era expressiva para a realidade da Comarca.

Por isso, a reprimenda final é de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Fixo o regime inicial fechado. As circunstâncias desfavoráveis apontadas (natureza

e em especial a quantidade; e tráfico interestadual) demonstram maior lesividade concreta do delito e exigem um agravamento do regime inicial para que a pena seja suficiente para a reprovação e prevenção (art. 33, §3º, CP). Independentemente da quantidade da pena, tais circunstâncias subjetivas desfavoráveis também impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, III, CP) ou a concessão do benefício da suspensão condicional (art. 77, II, CP).

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços a comunidade e prestação pecuniária, nos termos do dispositivo.

Eventual detração penal (art. 387, §2º, CPP), se for o caso, deverá ser analisada pelo Juízo da Execução, único com competência para verificar a presença ou não dos requisitos subjetivos.

D) CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu DANIEL DE OLIVEIRA RODRIGUES como incurso no art. 33, §4º, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06, na pena de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, regime inicial fechado, dias-multa fixados em 1/30 do salário mínimo.

Considerando o período já cumprido de prisão preventiva e o término da fase de instrução, com potencial direito a progressão de regime, concedo ao sentenciado a LIBERDADE PROVISÓRIA, mediante obrigação de manter seu endereço e telefone atualizado nos autos. Expeça-se alvará de soltura.

Autorizo a devolução do celular apreendido, servindo a presente como ofício.

Fica o réu condenado ao pagamento das custas (art. 804, CPP), observada eventual gratuidade concedida nos autos.

Expeça-se certidão de honorários, se for o caso, ficando a remuneração arbitrada em grau máximo.

Havendo interposição de recurso, intime-se a parte adversa para apresentação de contrarrazões e, oportunamente, subam os autos ao E. Tribunal de Justiça de São Paulo, com nossas homenagens.

Após o trânsito em julgado, oficie-se para destruição de eventual contraprova (art. 72, Lei 11.343/06) e comunique-se ao IIRGD e ao TRE.

Publique-se. Saem as partes intimadas em audiência. Cumpra-se.

Aruja, 7 de abril de 2022.